

1502129-47.2020.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Torres de Aguiar

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... apreendidos indica que o réu faz do tráfico de drogas seu meio de vida, ou seja, dedica-se à atividade criminosa, não podendo ser considerado como pequeno traficante, conforme entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça: "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTUM PROPORCIONAL À ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

1ª Vara Criminal

Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502129-47.2020.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502129-47.2020.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON ALEXANDRE SOUSA BESERRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar

Vistos.

JEFFERSON ALEXANDRE SOUSA BESERRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal porque, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na inicial, em ocasião de calamidade pública, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, cinco porções de maconha e, dentro de uma sacola plástica, mais 173 porções da mesma droga, substância esta que causa dependência física e psíquica. Foi também apreendida com o acusado a quantia de R\$345,00.

O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar. Recebida a denúncia, o réu foi citado.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, foi o réu interrogado.

Encerrada a instrução, foram convertidos os debates em memoriais.

O Ministério Público pediu a procedência da ação para a condenação do réu nos

termos da denúncia, diante da prova produzida. Requereu, ainda, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da quantidade de droga apreendida e dos maus antecedentes do acusado. Pugnou, ainda, pelo reconhecimento da circunstância agravante relativa à calamidade pública e pela não aplicação da causa especial de redução de pena. Ao final, pediu a fixação do regime inicial fechado e o perdimento da quantia apreendida.

Foi indeferido o pedido formulado pela Defesa para acareação entre a testemunha policial militar Wilson Roberto de Souza Junior e do Dr. Thiago Espinha Garcia, delegado de polícia que presidiu o auto de prisão em flagrante, a fim de esclarecer a destinação dada à sacola em que as drogas foram apresentadas na delegacia, bem como para nova oitiva da testemunha policial Wilson Roberto.

Em seus memoriais, a Defesa suscitou preliminar de nulidade da prova, alegando quebra da cadeia de custódia. No mérito, pugnou pela absolvição, em razão da nulidade da prova e, também, por falta de provas quanto à autoria do crime. Subsidiariamente, formulou pedidos relativos à dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base em seu mínimo legal, o afastamento da circunstância agravante relativa à calamidade pública, a aplicação da causa especial de redução de pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, por fim, a fixação de regime diverso do fechado e o cumprimento de pena em prisão domiciliar.

É o relatório.

DECIDO.

A preliminar suscitada pela Defesa confunde-se com o mérito e com ele será analisado.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, pelo auto de constatação, pelas fotografias de fls. 10/11, pelo laudo de exame químico-toxicológico, pela prova oral colhida, bem como pelo restante do conjunto probatório constante dos autos.

Também não restam dúvidas quanto à autoria desse delito.

Interrogado em Juízo, o acusado negou a prática do crime descrito na denúncia.

Disse que ajuda a cuidar da avó de sua esposa, residente na casa em frente à qual foi preso, levando-a a todos os lugares que precisa. Contou que havia acabado de entrar na casa daquela senhora para vê-la, pois ela havia caído e batido a cabeça, e depois sentou-se em um degrau em frente àquela casa, a fim de fazer uso de maconha, pois havia acabado de pegar duas “parangas” dessa droga, exibindo à câmera, durante a audiência virtual, um objeto ao qual se referiu como sendo uma porção de maconha. Interpelado pelo Juízo sobre ter ciência de que sua conduta em portar drogas ser crime, alegou desconhecimento. Aos questionamentos da Defesa, prosseguiu dizendo que, naquele momento em que estava sentado com a droga, viu a viatura da Baep virar a esquina e, com medo, dirigiu-se ao portão, arremessando as drogas que tinha para dentro do quintal de Renata. Contou que os policiais viram sua conduta, correram e o seguraram perto do portão. Alegou que os policiais pegaram o que lá havia e lhe disseram para comer e, diante de sua recusa e de sua conduta com os policiais, eles ameaçaram agredi-lo. Contou que não resistiu à prisão e foi algemado. Alegou que os policiais, então, viraram a viatura na primeira esquina à direita e, cerca de cinco minutos depois, outra viatura da Baep se aproximou, tendo policiais desta viatura entregado ao policial que o deteve uma sacola, e este atribuindo-lhe a propriedade da sacola, dizendo que seria preso, apontando a arma em sua direção e ameaçando agredi-lo. Disse que consome uma “paranga” de maconha ao longo de um dia, pagando por essa porção o valor de cinco reais. Contou que trabalhava fazendo “bicos” com marcenaria e carroto, pois estava auxiliando a avó de sua esposa à época.

Contudo, a negativa do réu e a versão por ele fornecida, além de não serem críveis, não encontram respaldo nos demais elementos de prova constantes dos autos.

A testemunha Wilson Roberto de Souza Junior, ouvida sob o crivo do contraditório, relatou que, durante patrulhamento de rotina em local já conhecido pela ocorrência do tráfico de drogas, avistou o réu, sozinho, parado, e viu que ele, ao perceber a presença da equipe, tentou evadir-se, mas foi detido em seguida. Narrou que, no trajeto de sua tentativa de fuga, o acusado dispensou uma sacola na calçada.

Declarou que, feita a busca pessoal, na posse do réu foi localizada a quantia de R\$345,00 em dinheiro e cinco porções de maconha, e, na sacola por ele dispensada, foram encontradas entre 170 e 173 porções daquele mesmo entorpecente, todos embalados com a mesma forma e tamanho. Disse que, após a abordagem, alguns parentes do acusado aproximaram-se do local dos fatos. Declarou que não conhecia o réu anteriormente aos fatos. Esclareceu não recordar se o acusado apresentou esclarecimentos sobre as drogas e dinheiro apreendidos. Relatou que ocupava a posição de comandante de equipe e ocupava o banco dianteiro direito, sendo que, na viatura, havia quatro policiais. Esclareceu não recordar com exatidão, mas avistou o acusado na rua, ao seu lado da viatura. Narrou que a recuperação das drogas foi feita pelo policial Cabo Lacerda e presenciou este momento. Declarou que o transporte da droga à delegacia foi feita por sua equipe, dentro da viatura. Não recordou se outras viaturas foram acionadas ou se estiveram no local dos fatos, esclarecendo que é normal que outras viaturas se aproximem, especialmente quando há aproximação de populares. Narrou que acompanhou a contagem e a pesagem das drogas que, quando foram encontradas no local dos fatos, estavam dentro de uma sacola e todo este material foi apresentado na delegacia. Consignou que não foi realizado registro fotográfico das drogas no local dos fatos, pois não é este o procedimento da polícia militar, esclarecendo que, na delegacia, durante a apreensão e elaboração do BOPM, é registrado o que foi apreendido. Relatou ter respondido a processo na Comarca de Santos, versando sobre resistência, com resultado de legítima defesa, e que não se referiu à manipulação de laudo pericial e de cena de crime. Consignou que está lotado no 45º BPMI desde novembro de 2021 e nada soube sobre apreensões ocorridas no 2º Batalhão da BAEP. Afirmou que nenhuma irregularidade ocorreu durante a ação policial referente aos fatos descritos na denúncia, pois nenhum material irregular ou ilícito havia em sua viatura, e nenhuma manipulação ocorreu no material arrecadado no local dos fatos e que foi levado diretamente à Autoridade Policial. Asseverou que nenhum membro de sua equipe agiu de forma irregular, sendo que nenhum deles permaneceu sozinho na posse das drogas encontradas.

No mesmo sentido, a testemunha Denis Jorge Melo Lacerda, ouvida em Juízo, narrou que realizava patrulhamento quando, ao virar uma esquina, avistou o réu, que tentou evadir-se da viatura e lançou uma sacola ao solo. Relatou que o réu foi alcançado e, feita a busca pessoal, no bolso de sua blusa, foram encontradas cerca de cinco porções de maconha e R\$345,00 em dinheiro. Afirmou que foi o policial que recuperou a sacola, sendo constatado que ela continha cerca de 170 a 173 porções daquele mesmo entorpecente encontrado com o réu. Declarou que, informalmente, o réu admitiu que estava praticando o crime para alimentar sua família, pois estava desempregado há algum tempo, esclarecendo que esta mesma versão foi dada pelo réu no boletim de ocorrência lavrado por sua equipe. Relatou que, no momento da abordagem, havia algumas pessoas na rua, mas não soube dizer se estavam com o réu e elas não se aproximaram da equipe, inclusive por segurança. Consignou que familiares do acusado residiam próximo ao local, mas não recordou de nenhum que tenha presenciado a abordagem e o encontro das drogas. Disse que não conhecia o réu anteriormente aos fatos. Declarou que, feita a condução do acusado e da droga à delegacia, lá ocorre a apreensão do entorpecente. Disse que acompanhou a pesagem e contagem das drogas em solo policial e não soube qual o destino dado à sacola, mas afirmou que tanto as drogas quanto a sacola foram apresentadas na delegacia. Esclareceu que, possivelmente, foi anexada ao BOPM a fotografia da sacola apresentada. Não soube se a confissão informal do réu ocorreu antes ou depois de ser dada a ele voz de prisão, consignando que, ao ser encontrado algo ilícito, como praxe é perguntado ao abordado o motivo dos fatos. Disse que foi feita a comunicação ao réu de permanecer em silêncio e não recordou o teor de seu depoimento em solo policial. Afirmou que não praticou qualquer irregularidade ou ilegalidade praticada durante a ação policial, o que também não foi feito por algum membro de sua equipe. Consignou que é realizada constante ronda feita pelo departamento de corregedoria da polícia e nenhum material irregular é levado na viatura. Disse que não há procedimento ou equipamento da polícia militar para lacre do material encontrado, e o que é localizado é encaminhado à delegacia, onde é feita a apreensão.

A testemunha de defesa Renata Sbravatti Dias disse que o réu é marido de sua sobrinha e declarou que não presenciou o momento da sua abordagem e de sua prisão, que ocorreu à porta de sua casa, à noite, em horário que não recordou. Disse que estava na cozinha de sua casa, com sua neta, quando visualizou um vulto em seu quintal e, então, viu que se tratava de um policial que ali estava e que abaixou-se três vezes e pegou três coisas do chão. Declarou não ter visto o que o policial pegou e quando o questionou, ele nada respondeu e disse para que não saísse da casa. Disse que o policial, então, fechou o portão e saiu. Relatou que permaneceu dentro de sua casa, com sua neta, e depois soube que o réu havia sido preso porque estava com três porções de maconha. Declarou que há somente sua casa em seu terreno e, em sua residência, moram sua sogra, seu marido e seus filhos. Disse que o acusado trabalha como pedreiro e com marcenaria e, quando foi detido, ele levava sua sogra, que havia caído, todos os dias ao hospital, para onde se dirigia logo cedo e lá permanecia o dia inteiro, mas fazia "bicos" como ajudante de pedreiro. Contou que o acusado fazia uso de maconha, mas nunca o viu consumir a droga. Disse que não viu nenhuma sacola no local dos fatos.

A testemunha de defesa Rafael Nonato da Silva disse conhecer o acusado há muitos anos, pois as famílias são próximas. Declarou que reside em frente à casa de Renata, Nena e Nice, onde viu o réu ingressar, após cumprimentá-lo. Disse que também viu uma viatura policial chegar ao local e viu os policiais ingressarem naquele mesmo local. Relatou que os fatos ocorreram à noite, por volta de 20 a 21h, e declarou que não conseguiu ver o que estava ocorrendo dentro daquela casa, pois estava ao lado oposto da rua e a viatura policial impedia sua visão. Disse que não permaneceu vendo o que estava ocorrendo por cerca de cinco minutos e, então, entrou em sua residência. Disse que não viu nada na mão do réu antes de ele entrar na casa de Renata e o viu entrar normalmente, como ele sempre faz. Contou ter conhecimento de que o acusado faz uso de maconha de vez em quando e disse que ele sempre trabalhou fazendo "bicos" em marcenaria. Disse que o acusado trajava uma camisa de cor clara e bermuda de cor escura na data dos fatos.

Não há dúvidas, portanto, sobre a conduta criminoso do acusado, no que se refere ao tráfico de drogas, diante das provas produzidas.

Ressalta-se a palavra das testemunhas policiais, que de maneira segura, uniforme e convincente, descreveram com detalhes como ocorreu a abordagem do réu e a localização e apreensão da droga.

Não há nos autos qualquer elemento idôneo hábil a retirar a credibilidade do testemunho policial.

Como já se decidiu "é bem sabido que não furta a lei validade aos depoimentos de policiais, tanto que sequer os isenta do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, se vierem sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre é conferir a tais declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, conferindo-lhes, ou não, segundo seu livre poder de convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética, de veracidade a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente de segurança para, ao depois, quando ele fosse convocado a prestar contas de sua atuação, negar-lhe valor, aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não diz a verdade" (Apelação criminal nº 112.195-3/1, Santos, Rel. Des. Canguçu de Almeida, em 07/10/1991, 2ª Câmara Criminal). Aliás, mostra-se "imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que o depoimento de policiais responsáveis pela segurança pública, não podem ser desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem função de salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento" (TJSP - AP - Rel. Walter Guilherme - j. 10.03.98 - JTJ 214/284). Ademais, o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de manifestar-se favoravelmente à validade desses depoimentos. A propósito, registro: "Tóxicos - Tráfico - Prova testemunhal: Depoimento de policiais. A prova testemunhal obtida

por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. Precedente" (STF - 2 T.- HC n. 74.522-9/AC - Rel. Min. Maurício Correa - DJU 13/12/96, pág. 50.167).

"Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais -Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF 1a Turma - HC n. 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189).

No mesmo sentido:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO INCORRETO. MENORIDADE RELATIVA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO À MÍNGUA DE PEDIDO NO RECURSO MINISTERIAL. REGIME FECHADO. PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada em poder do réu.

2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10).

Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP - Rel. Min. Moura Ribeiro - j. 27.05.14; RHC 45.173/SP - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 26.05.14 e HC 109.105/SP - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - j. 23.02.10).

3. Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme,

segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminosa. Precedentes do STF (AP 470/MG – Pleno – Voto Min. Cezar Peluso – j. 28.08.12 – Revista Trimestral de Jurisprudência – Volume 225 – Tomo II – pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG – Pleno – Voto Min. Luiz Fux – j. 28.08.12 – Revista Trimestral de Jurisprudência – Volume 225 – Tomo II – pág. 838/842).

4. Dosimetria da pena estabelecida de modo incorreto. Menoridade relativa. Correção de ofício.

5. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primordialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF (HC 121.057/SP – Rel. Min. Luiz Fux – j. 25.02.14 – DJU 18.03.14; HC 118.380/SP – Rel. Min. Teori Zavascki – j. 04.02.14 – DJU 14.02.14; HC 116.541/ES – Rel. Min. Gilmar Mendes – j. 21.05.2013 – DJE 06.06.13; HC 109.236/SP – Rel. Min. Cármen Lúcia – j. 13.12.11 – DJU 14.23.12). Manutenção à míngua de pedido no recurso Ministerial.

6. O regime inicial de cumprimento de pena para os crimes de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto.

7. Provimento do recurso do Ministério Público e correção, "ex officio", da dosimetria da pena." (Ap. nº 3003382-41.2013.8.26.0471; Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Porto Feliz; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 01/06/2016; Data de registro: 07/06/2016) (grifo nosso)

"Tráfico de entorpecentes – Agente que mantém em depósito e guarda substância estupefaciente – Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda – Caracterização

Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "manter em depósito" e de "guardar".

Tráfico de entorpecentes – Agente que vende substância estupefaciente a policial pensando tratar-se de consumidor – Apreensão que quantidade expressiva de entorpecente por ele guardado – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Alegação do agente no sentido de ser apenas usuário incompatível com o conjunto probatório e com a quantidade de entorpecente apreendida

Realiza o tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 o agente que vende substância estupefaciente a policial, pensando tratar-se de consumidor. Ainda que assim não fosse, o próprio estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente não é necessário para caracterizar o tráfico, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "manter em depósito" e "guardar". A ulterior alegação de que a substância ilícita se destinaria apenas ao uso próprio não se coaduna com a dinâmica de sua apreensão, devendo ser afastada.

No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Cálculo da Pena – Tráfico de Entorpecentes – Exacerbação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos nos art. 59 do CP em razão da quantidade e a variedade do entorpecente apreendido – Admissibilidade

Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06) é perfeitamente admissível a elevação da pena-base com base na variedade e qualidade do tóxico apreendido, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos.

Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes – Desnecessidade de comprovação de nexos causal entre a conduta do acusado e a circunstância da apreensão ter ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino – Causa de aumento de pena (art. 40, III, da Lei nº 11.343/06) de natureza objetiva – Reconhecimento

Imperioso o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 sempre que for constatado que o tráfico de drogas estava sendo praticado nas imediações de estabelecimento de ensino. Em tal situação, torna-se dispensável a comprovação de que o acusado comercializava entorpecentes erigindo diretamente os alunos da escola como público alvo, uma vez cuidar-se de causa de aumento de natureza objetiva.” (Ap. nº 0039706-12.2014.8.26.0224; Relator(a): Grassi Neto; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 19/05/2016; Data de registro: 19/05/2016) (grifo nosso)

O esforço da Defesa em desqualificar os depoimentos das testemunhas policiais militares não é suficiente para retirar a força probante deles.

Frise-se que os depoimentos destas testemunhas, colhidos durante a instrução criminal, mostram-se coerentes e harmônicos quanto às circunstâncias em que se deu a abordagem do réu e a localização do entorpecente, estando em harmonia com suas declarações prestadas na fase extrajudicial.

Note-se que as testemunhas policiais bem relataram ter avistado o acusado que, ao notar a equipe policial, empreendeu fuga e dispensou a sacola que ele trazia consigo. Afirmaram que, em busca pessoal, encontraram com o réu cinco porções de maconha e a quantia de R\$345,00 em dinheiro e asseveraram que, recuperada a sacola lançada ao solo pelo réu, nela constataram haver entre 170 e 173 porções da mesma droga localizada na posse física do acusado.

Acrescentou a testemunha policial Wilson que os entorpecentes encontrados com o réu e também na sacola por ele dispensada eram da mesma natureza e também estavam embalados da mesma forma e tamanho. Consignou, ainda, que o local onde o acusado foi abordado já era conhecido pela ocorrência do tráfico de drogas.

Não há dúvidas, portanto, que o acusado estava portando cinco porções de maconha e que eram também de propriedade dele as 173 porções acondicionadas na sacola por ele dispensada e recuperada pelos policiais.

De outro lado, as declarações das testemunhas arroladas pela Defesa não abalaram em nada os demais elementos probatórios constantes dos autos, notadamente o depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu.

Ambas as testemunhas claramente tentaram beneficiar o réu. Contudo, não presenciaram o exato momento de sua abordagem e nada mais puderam esclarecer sobre os fatos.

Renata disse que estava dentro de sua casa e viu um policial em seu quintal, pegando coisas no chão. Declarou que não saiu de sua casa, não viu a abordagem do acusado e sua prisão, nem viu o que foi recolhido pelos policiais, tendo sabido que o réu havia sido preso por estar portando três porções de maconha.

Não haveria como Renata ter visto, portanto, o réu dispensar a sacola contendo drogas.

Já a testemunha Rafael disse ter visto o acusado, sem nada nas mãos, ingressando pelo portão de Renata, normalmente, como ele sempre fazia, após cumprimentá-lo. Disse ter visto, então, uma viatura policial chegar e policiais ingressarem naquela mesma casa – de Renata –, porém não viu o que ocorreu porque a viatura bloqueava sua visão. Disse que sequer aproximou-se para tomar ciência do que ali estava ocorrendo e somente observou o que estava ocorrendo por cinco minutos.

Rafael, portanto, não teria mesmo visto uma sacola sendo lançada pelo réu.

De qualquer forma, vale salientar a incongruência entre o relato de Rafael e a versão apresentada pelo réu em seu interrogatório.

Enquanto Rafael disse nada ter visto com o réu, o próprio acusado alegou que estava

portando duas porções de maconha e que, ao ver a viatura policial, dirigiu-se ao portão da casa de Renata, lançou a droga para dentro daquele quintal e foi detido pelos policiais perto do portão.

Acerca do teor do interrogatório do acusado, também merece destaque sua alegação de que se levantou do degrau em que estava sentado à porta da casa de Renata, lançando as duas porções de maconha que alegou estar portando para dentro do quintal, diante de seu temor ao ver a viatura policial.

Isto porque, durante seu interrogatório judicial, realizado por meio de videoconferência, o acusado mostrou à câmera um objeto que afirmou ser uma "paranga" de maconha e, ao ser questionado por este Magistrado sobre ter ciência de que estava cometendo um crime ao portar a droga, alegou desconhecimento.

Infere-se de sua conduta que o réu procurou esquivar-se da responsabilidade pelos fatos, ora dizendo temer a presença policial, inclusive dispensando porções de drogas, ora dizendo sequer ter ciência de que portar drogas caracteriza um crime.

Dessa forma, a versão apresentada pelo acusado, além de não se mostrar crível, restou absolutamente isolada do contexto probatório, devendo-se considerar os demais elementos de convicção existentes e produzidos durante o processo.

Na hipótese, seria mesmo um contrassenso pretender que a versão fornecida pelo réu sobreponha-se ao depoimento dos policiais encarregados de sua prisão, depoimentos estes que estão em harmonia com as demais circunstâncias que envolvem os delitos.

Em outras palavras, impossível seria desmerecer os depoimentos policiais, que sequer conheciam o acusado anteriormente aos fatos, bem como as diligências realizadas no curso da ação penal, pois são absolutamente aptos e suficientes para embasarem a inequívoca conclusão de que o réu é de fato traficante.

No presente caso os elementos de convicção são contundentes, seja em virtude da quantidade das drogas apreendidas, seja pela ação policial, tudo aliado à negativa isolada do réu.

Dessa forma, pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do acusado, evidencia-se, pois, a realização do tráfico por ele.

Em arremate, a intenção mercantilista do acusado deriva da quantidade, natureza e variedade de drogas encontradas, e das demais circunstâncias em que as drogas e o dinheiro foram apreendidos.

De mais a mais, "para caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos variados como as circunstâncias da prisão, a quantidade de entorpecente, o local da infração etc." (TJRJ - AC 1.327/92 - Rel. Adolphino A. Ribeiro - RDTJRJ 20/310).

Apenas para consignar, também não há nada nos autos que pudesse justificar a conclusão de que o réu estaria sendo acusado injustamente da prática do delito de tráfico de drogas.

As graves acusações feitas contra os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu, entre outras, de que "Sabemos que alguns "bandidos", vestidos de policiais militares no Estado de São Paulo tem se equipado com o chamado "kit Flagrante", usado exatamente para forjar prisões em flagrantes em caso de tráfico, obtenção de suborno, etc." (sic) e de que "No caso presente, há evidentes indicativos, já que os policiais de forma deliberada violaram a cadeia de custódia, e sequer apreenderam a suposta "sacola" (sic), não vieram acompanhadas de qualquer elemento probatório.

Argumentos genéricos que visam a desprestigiar a Polícia como um todo em nada influenciam na prova colhida no presente caso.

Nada há a indicar que os policiais militares responsáveis pela prisão do acusado cometeram qualquer irregularidade quando da abordagem, da localização das drogas e da condução destas à delegacia, para apresentação à Autoridade Policial que, então, realizou a apreensão formal das substâncias ilícitas.

Quaisquer procedimentos judiciais a que tenham as testemunhas policiais respondido ou notícias veiculadas sobre irregularidades sobre as quais não há demonstração de envolvimento destas testemunhas em nada infirmam a validade de seus relatos quanto aos fatos tratados nesta ação penal.

Nada foi trazido pela Defesa a indicar relação entre os processos elencados à fl. 358 e a conduta dos policiais no crime perpetrado pelo acusado e apurado nestes



autos, ou mesmo que tenham as testemunhas qualquer envolvimento com a notícia jornalística veiculada e exposta à fl. 359.

Outrossim, não prospera a alegação formulada pela Defesa quanto à eventual nulidade de prova, em razão de quebra da cadeia de custódia.

A presunção de validade e legitimidade dos atos praticados por funcionários públicos transfere à Defesa o ônus de demonstrar de forma concreta o descumprimento das formalidades legais e essenciais do ato e, especificamente, que o material apreendido foi corrompido ou adulterado, de forma a causar prejuízo à Defesa e modificar o conteúdo da prova colhida.

Nada disso foi comprovado.

Vale consignar que a eventual violação da cadeia de custódia, disciplinada nos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, não significa, em absoluto, a inadmissibilidade ou a nulidade da prova colhida. Eventuais irregularidades precisam ser analisadas pelo julgador em cotejo com todos os demais elementos de convicção colhidos durante a instrução processual, para que se conclua se aquilo que foi questionado retira a confiabilidade da prova.

Somente depois dessa análise poderá o Juízo decidir pela imprestabilidade da prova ou declará-la nula, se concluir que a eventual quebra da cadeia de custódia retirou qualquer sustentação da prova.

No presente caso, verifica-se, ao contrário do que alegou a Defesa, que todas as drogas recolhidas pelos policiais militares no local dos fatos e apresentadas à Autoridade Policial - conforme seus relatos que não foram minimamente contrariados por qualquer prova trazida pela Defesa - foram devidamente identificadas e discriminadas no auto de exibição e apreensão de fl. 8, fotografadas acondicionadas em embalagem transparente, devidamente lacrada sob o nº 4217720 e, com esta mesma numeração de lacre, foram recebidas pela polícia técnico-científica e periciadas (laudo de exame químico-toxicológico de fls. 283/285), tudo a demonstrar o cumprimento rigoroso dos procedimentos legais para sua apreensão.

Nenhuma irregularidade há na ausência de apreensão formal, pela Autoridade Policial, da sacola onde as drogas (estas sim ilícitas e que demonstram a materialidade do delito de tráfico de drogas), foram localizadas.

A falta de apreensão formal da sacola pela Autoridade Policial, visto que absolutamente prescindível para a elucidação do caso, não indica que esta tenha "sumido", ou que qualquer agente de segurança, membro da polícia civil ou da polícia militar, tenha "sumido" com ela, ou que ela sequer tenha existido.

Ao revés do aduzido pela Defesa, de que "A polícia Civil não apresentou registro que comprovem a apreensão da "sacola", aliás, ao contrário, afirmou que a "sacola" não foi apreendida pela polícia militar" (sic) (grifo nosso), a Autoridade Policial (fl. 316) consignou apenas que a sacola não foi apreendida - o que se infere do próprio auto de exibição e apreensão.

Saliente-se que o próprio réu em seu interrogatório, ao alegar irregularidade no procedimento adotado pelos policiais, fez menção à sacola que os policiais teriam recebido de agentes de outra viatura, ainda nas imediações do local dos fatos.

E para que não parem dúvidas, consigne-se, mais uma vez, que nada há nos autos a demonstrar que as testemunhas policiais tenham de alguma forma manipulado ou cometido qualquer irregularidade na condução das drogas à delegacia, uma vez que seus depoimentos, colhidos sob o crivo do contraditório, são absolutamente coesos e coerentes com as circunstâncias em que se deu a abordagem do acusado e localização de todos os entorpecentes de propriedade dele, e demonstram o crime perpetrado pelo acusado.

Dessa forma, provadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, considerando-se a natureza, a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e as circunstâncias da prisão, a condenação do réu em relação a esse delito é medida que se impõe.

Procedente a ação penal, passo a dosar a pena.

Atendendo às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o acusado possui Maus antecedentes, conforme certidão de fl. 21, motivo pelo qual aumento a pena-base em 1/6, a qual resta fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-

multa, no valor mínimo legal.

Na segunda fase de fixação da pena, verifico que o delito foi cometido em ocasião de calamidade pública. A agravante tem caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência. De qualquer forma essa circunstância não pode ser ignorada, pois o isolamento social e a quarentena, em razão da pandemia, facilitam a prática do crime. Impõe-se, portanto, o aumento de pena pelo reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal em mais 1/6, a qual resta fixada em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor já estabelecido. Não incidem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes de pena. Na terceira fase da dosimetria da pena, não há causa de aumento a ser reconhecida, e não se pode reconhecer a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, diante da grande quantidade da droga apreendida (178 porções, totalizando 301,9 gramas de maconha).

Ressalte-se que o próprio acusado, em seu interrogatório, ao alegar ser usuário de entorpecente, disse que cada porção de 2 (dois) gramas ou 2,5 (dois e meio) gramas são suficientes para a confecção de um cigarro de maconha, tudo a demonstrar, concretamente, que o réu não se trata de pequeno traficante, mais sim de um grande disseminador dos entorpecentes.

Ademais, a grande quantidade dos entorpecentes apreendidos indica que o réu faz do tráfico de drogas seu meio de vida, ou seja, dedica-se à atividade criminoso, não podendo ser considerado como pequeno traficante, conforme entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTUM PROPORCIONAL À NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. III - Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para a fração do tráfico privilegiado, ante a natureza bastante lesiva da substância ilícita (crack), em consonância com o atual entendimento do col. Pretório Excelso, bem como desta eg. Corte Superior de Justiça. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 630.134/RS, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

Torno essa pena definitiva na ausência de outras modificadoras.

Considerando as peculiaridades do presente caso e as condições previstas no artigo 59 do Código Penal, cuidando-se de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, cujo aspecto altamente nocivo à sociedade em geral ninguém desconhece, por certo que não se afigura socialmente adequada e recomendável à situação a aplicação de penas alternativas ou outros benefícios que, por sinal, implicaria sensação de impunidade e incentivo à prática delituosa, frustrando-se a expectativa social, que exige e espera, em tais condições, efetiva e eficaz resposta à criminalidade cada vez mais crescente, motivos pelos quais fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena.

Não estão presentes os requisitos para substituição da pena privativa por liberdade

por restritiva de direitos. Também incabível o sursis.

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu JEFFERSON ALEXANDRE SOUSA BESERRA, qualificado nos autos, às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, por incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Por não estarem presentes os requisitos legais da prisão preventiva, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Ressalte-se que a prisão preventiva do acusado havia sido revogada no ano de 2020, em razão de doença cardíaca por ele demonstrada e em atenção à Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, em vigor naquele momento.

Assim, não estando o acusado preso cautelarmente, não há que se falar, neste momento, em substituição de sua prisão pela domiciliar, cujos requisitos, quando do cumprimento de pena por condenação definitiva, deverão ser analisados pelo Juízo das Execuções Criminais (artigo 117 da Lei de Execução Penal).

Decreto o perdimento dos valores apreendidos nos autos em favor da União, com fundamento no artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Vicente, 14 de outubro de 2022.

ALEXANDRE TORRES DE AGUIAR  
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA